

1503333-95.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar que não há nenhuma prova que permita concluir que o acusado ostentava capacidade financeira para a aquisição daquele número considerável de porções.

Além disso, embora afirme que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503333-95.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503333-95.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIS RODRIGO DE MELO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Francis Rodrigo de Melo foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta das 12h40min, na Rua Orlando Girarde Franco nº 157, Jardim Santa Teresinha, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de local de trabalho coletivo e de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, em forma de "crack", pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 104/105) e a denúncia foi recebida aos 18 de maio de 2022 (fls. 129/130).

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer, preliminarmente, a instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, pede a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu e requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, consigno que era mesmo o caso de indeferir o pedido formulado pela defesa para instauração de incidente de dependência toxicológica, pois não há prova documental que indique a dependência alegada pelo réu, sendo certo que meras afirmações não bastam para a instauração do incidente. A esse respeito, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA O DIREITO DO PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO MANDAMUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT QUANTO A ESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. 1. Correto o acórdão ora impugnado quanto ao fundamento de que não seria possível aferir, na espécie, a semi-imputabilidade do Paciente, pois nem sequer foi instaurado, em qualquer fase do processo, o incidente de insanidade mental - única forma possível de se aferir o estado mental do Acusado. Além disso, não consta nos autos qualquer insurgência quanto à ausência de instauração do referido incidente. 2. Observa-se, da análise dos documentos colacionados aos autos, que não houve, durante a instrução criminal, e tampouco restou demonstrado neste mandamus, dúvida relevante acerca da saúde mental do ora Paciente capaz de justificar a instauração do incidente de ofício pelo Magistrado de primeira instância. 3. A dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado enseja a instauração do incidente de insanidade mental, sendo que o requerimento pela defesa, por si só, não obriga o Juiz a determinar a sua realização, nem tampouco a instauração do procedimento de ofício. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 142.344/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, DJ de 8/9/2011, 5ª Turma)."

Veja-se que o único documento juntado pela defesa a esse respeito indica tratamento realizado no ano de 2013, isto é, 8 anos antes do fato aqui tratado, inexistindo qualquer indicativo nos autos de que, nesse período, o acusado tornou a consumir drogas.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 10); pelo laudo pericial do local (fls. 139/143); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 136/138) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Henrique da Silva disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é uma praça, avistou o acusado e resolveu abordá-lo. Na cintura do acusado foram encontradas 48 porções de crack e R\$ 80,00 em dinheiro. O acusado confessou que ali estava vendendo a droga, pois estava passando necessidade. Nunca havia abordado o acusado. No momento da abordagem, o acusado conversava com outra pessoa, estando ambos fora do veículo.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Fábio dos Santos Codogno.

Em solo policial, o acusado Francis Rodrigo de Melo disse que realmente estava pelo local vendendo drogas, quando foi abordado pelos guardas municipais. Confessou a prática do delito, informou que estava passando por necessidades financeiras e por isso agiu dessa forma. Disse que pegou a droga para vender de um homem desconhecido e que queria ganhar um dinheiro para poder comprar um frango, bem como pagar a energia elétrica de sua casa que já está há 3 meses em atraso.

Em juízo, o acusado disse que foi ao local com um local para buscar droga para seu consumo pessoal. Disse que consumiria com outras três pessoas. Informa que pegou a droga, entrou no carro, mas antes que deixassem o local, foram abordados. Quanto ao teor de seu interrogatório policial, afirma que os guardas civis recomendaram que confessasse a prática do tráfico. Disse que o dinheiro apreendido seria utilizado para abastecer o veículo. É usuário de droga desde 2012. Não conhecia os guardas civis.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não

torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332). Nem se diga que os guardas civis possuem interesse na condenação ou em prejudicar o acusado, pois, em interrogatório judicial, o próprio increpado confirmou que as porções apreendidas estavam em sua posse, apenas inovando a versão exposta em solo policial, pois sustentou que se destinavam a seu próprio consumo e de outras três pessoas.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar que não há nenhuma prova que permita concluir que o acusado ostentava capacidade financeira para a aquisição daquele número considerável de porções.

Além disso, embora afirme que já estava no interior do veículo, em companhia de pessoa que também consumiria o entorpecente, os guardas civis municipais afirmaram que o acusado e aquela outra pessoa conversaram em pé, ao lado do veículo, nada indicando, portanto, que o acusado realmente deixaria o local em companhia daquele indivíduo.

Desse modo, inegável que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Nem se diga que o acusado praticava o tráfico de drogas para sustentar seu vício, pois não há prova nenhuma que indique tratar-se de usuário contumaz, apenas a sua alegação.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois ostenta maus antecedentes (fls. 37), de modo que majoro a pena-base e fixo pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a reconhecer.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 139/143) revela que os fatos ocorreram existem estabelecimento de ensino e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o

conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o acusado ostenta condenação definitiva por prática idêntica à apurada nos presentes autos e que configura maus antecedentes, o que impossibilita a incidência da benesse.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Francis Rodrigo de Melo à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que ostenta maus antecedentes, tratando-se de outra condenação definitiva pelo crime de tráfico de droga, o que revela que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fl. 134), pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 14 de julho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA